DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 01-2024-CYAM-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje de Emergencia.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L

Demandado : Municipalidad Distrital de San Salvador de Quije.

ARBITRO DE EMERGENCIA : Abg. Carol Yanely Apaza Moncada.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

PEDIDO CAUTELAR : Medida Cautelar de No Innovar

FECHA DE INICIO : 10 de enero de 2024.

FECHA DE CONCLUSION : 22 de enero de 2024.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

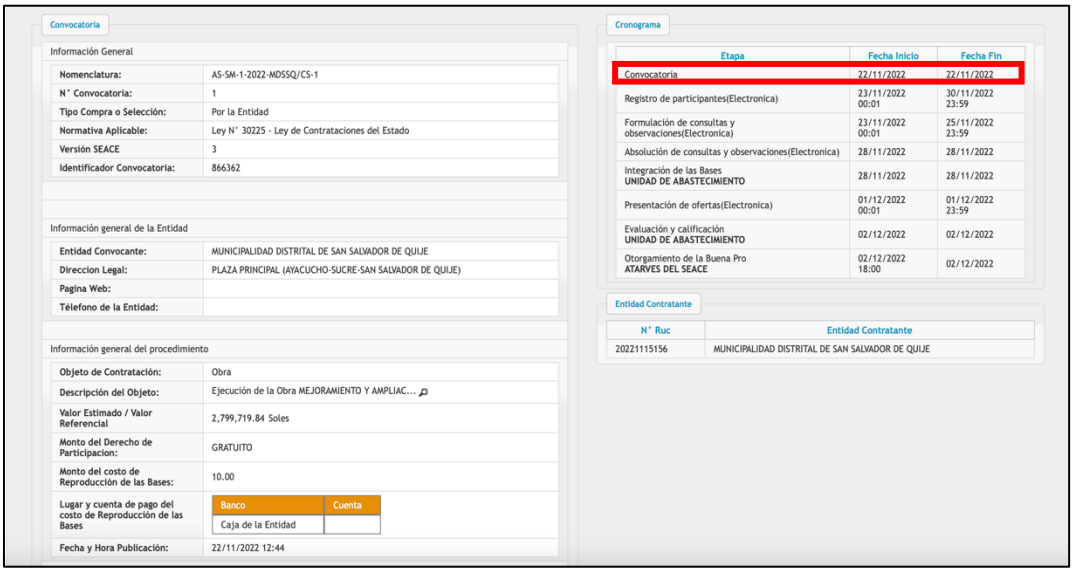
Arbitraje de emergencia
Decisión N° 4
22 de enero de 2024.

I. DECLARACIÓN:

1. Este Árbitro de Emergencia declara haber revisado todos y cada uno de los documentos presentados por las partes dentro de este arbitraje de emergencia, analizándolos y adjudicándoles el valor probatorio que les corresponde, aun cuando en la presente Decisión no se haga mención expresa a alguno de ellos o al valor probatorio que le ha sido asignado.

II. NORMATIVA APLICABLE:

2. La convocatoria del procedimiento de selección del Contrato N° 009-2022-MDSSQ/UA para la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en la localidad de Lluchcanta, del distrito de San Salvador de Quije – provincia de Sucre – Departamento de Ayacucho" (en adelante, el Contrato), del cual deriva la presente controversia, fue realizada el 22 de noviembre de 2022, conforme se aprecia de la ficha del procedimiento de selección del aplicativo de la página web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado:



Convocatoria

Información General

Nomenclatura:	AS-SM-1-2022-MDSSQ/CS-1
N° Convocatoria:	1
Tipo Compra o Selección:	Por la Entidad
Normativa Aplicable:	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
Versión SEACE	3
Identificador Convocatoria:	866362

Información general de la Entidad

Entidad Convocante:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE
Direccion Legal:	PLAZA PRINCIPAL (AYACUCHO-SUCRE-SAN SALVADOR DE QUIJE)
Pagina Web:	
Télefono de la Entidad:	

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación:	Obra
Descripción del Objeto:	Ejecución de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIAC...
Valor Estimado / Valor Referencial	2,799,719.84 Soles
Monto del Derecho de Participacion:	GRATUITO
Monto del costo de Reproducción de las Bases:	10.00
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	Banco: Caja de la Entidad; Cuenta:
Fecha y Hora Publicación:	22/11/2022 12:44

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	22/11/2022	22/11/2022
Registro de participantes(Electronica)	23/11/2022 00:01	30/11/2022 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	23/11/2022 00:01	25/11/2022 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	28/11/2022	28/11/2022
Integración de las Bases UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	28/11/2022	28/11/2022
Presentación de ofertas(Electronica)	01/12/2022 00:01	01/12/2022 23:59
Evaluación y calificación UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	02/12/2022	02/12/2022
Otorgamiento de la Buena Pro ATARVES DEL SEACE	02/12/2022 18:00	02/12/2022

Entidad Contratante

N° Ruc	Entidad Contratante
20221115156	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE

3. En ese sentido, resultan aplicables las normas que estuvieron vigentes al momento en que se realizó la convocatoria; es decir, el TUO de la Ley N° 30225, **Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (que comprende la Ley N° 30225 y sus modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444), y modificada por la Ley N° 31433 y Ley N° 31535 (en adelante, la LCE); así como el **Reglamento de la Ley de**

Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF (en adelante el RLCE).

4. En efecto, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del RLCE, establece que "Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de selección."; por tanto, queda claro que, al Contrato se le aplica las normas vigentes al momento de su convocatoria, las cuales acababamos de detallar.

III. CONVENIO ARBITRAL:

5. La Cláusula Vigésima del Contrato N° 009-2022-MDSSQ/UA para la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en la localidad de Lluchcanta, del distrito de San Salvador de Quije – provincia de Sucre – Departamento de Ayacucho" (en adelante, el CONTRATO), contiene el Convenio Arbitral y establece lo siguiente:

> "**<u>CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS</u>**
>
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
>
> El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo

previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado."

6. Del convenio arbitral se aprecia que las partes pactaron, entre otros, someterse a un arbitraje para resolver sus controversias; sin embargo, no precisaron el tipo de arbitraje y menos la institución arbitral a la que recurrirían; por lo que, corresponde que el arbitraje sea institucional siendo la institución arbitral de libre elección de la parte interesada, conforme lo establece el inciso 226.2 del artículo 226 del RLCE, que a la letra dice:

> "226.2. En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral:
>
> d) Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje."

7. En ese sentido, no se verifica impedimento alguno para que la parte interesada, en este caso, la empresa HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. (en adelante, el Contratista) haya recurrido al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD (en adelante, el CECARD), el cual cuenta con el procedimiento de arbitraje de emergencia, conforme a continuación pasaremos a desarrollar.

IV. APLICACIÓN DEL ARBITRAJE DE EMERGENCIA:

8. El artículo 65 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD (en adelante, el Reglamento de Arbitraje del Centro), establece lo siguiente:

> "Artículo 65°.- Medida Cautelar emitida por Árbitro de Emergencia
>
> 1. Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiera medidas cautelares urgentes puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud.
>
> 2. Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora.

3. Se extingue la competencia del Árbitro de Emergencia por la constitución del Tribunal Arbitral.

4. El derecho de las partes de recurrir a un Árbitro de Emergencia no impide que cualquiera de ellas pueda solicitar a la autoridad judicial competente que dicte medidas cautelares."

9. Conforme se aprecia, el presupuesto base para iniciar un arbitraje de emergencia es que no exista un Tribunal Arbitral constituido, requisito que en el presente caso se cumple de acuerdo a lo informado por las partes en la Audiencia Especial realizada el día 19 de enero de 2024, en donde, ante la consulta efectuada por el Árbitro de Emergencia sobre el estado del proceso arbitral, indicaron que aún se encuentra pendiente la designación de Árbitro, conforme puede apreciarse en el minuto 01:22:26 del video de la audiencia.

10. En tal medida, es perfectamente aplicable el arbitraje de emergencia regulado en el Reglamento de Arbitraje del CECARD.

11. De acuerdo con ello, se deja constancia que ninguna de las partes ha cuestionado el inicio del procedimiento de Arbitraje de Emergencia ante el CECARD.

V. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO DE EMERGENCIA:

12. El 10 de enero de 2024, a través de la CARTA N° 010-2024- SG-CARD-CECARD/AYA, el CECARD comunicó a la abogada Carol Yanely Apaza su designación como Árbitro de Emergencia

13. En la misma fecha, la abogada Carol Yanely Apaza aceptó la designación realizada y presentó la documentación correspondiente, constituyéndose de esta forma dentro del plazo establecido en el mencionado REGLAMENTO.

14. Las partes no formularon recusación contra el Árbitro de Emergencia.

VI. PRINCIPALES ACTUACIONES:

15. Mediante el escrito de fecha 9 de enero de 2024, con sumilla: "SOLICITO INICIO DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA Y SE DICTE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR", subsanado a través del escrito de fecha 10 de enero de 2024, con sumilla: "SUBSANO OBSERVACIONES Y OTROS", el contratista presentó ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD (en adelante, el CECARD) una solicitud de arbitraje de

emergencia, peticionando la concesión de una medida cautelar de no innovar.

16. Mediante Decisión N° 1 de fecha 10 de enero de 2024, se puso en conocimiento de la Municipalidad Distrital de San Salvador de Quije (en adelante, la Entidad) la solicitud presentada por el Contratista.

17. A través del escrito presentado por el Contratista el 11 de enero de 2024, con sumilla: "SOLICITAMOS PRONUNCIAMIENTO CAUTELAR PROVISIONAL", se solicita que la Árbitro de Emergencia emita un pronunciamiento provisional para que la Entidad se abstenga de ejecutar las cartas fianzas entregadas como garantías de fiel cumplimiento, adelantos directo y de materiales.

18. Con Decisión N° 2 de fecha 12 de enero de 2024, se concedió la medida provisional solicitada por el Contratista y se ordenó a la Entidad no ejecutar las cartas fianzas emitidas como garantías de fiel cumplimiento por adelantos directo y de materiales, hasta que se adopte la decisión definitiva sobre la solicitud de medida cautelar presentada por el Contratista.

19. Mediante Decisión N° 03 de fecha 16 de enero de 2024, se citó a las partes a una Audiencia Especial para el día 19 de enero de 2024 a horas 08:30 a.m.

20. El día 19 de enero de 2024 a horas 08:30 a.m., se llevó a cabo la Audiencia Especial, en la que ambas partes tuvieron la oportunidad de sustentar sus respectivas posiciones y responder las preguntas formuladas por el Árbitro de Emergencia.

VII. CONSIDERANDO:

A. POSICIÓN DEL CONTRATISTA

SOBRE EL PEDIDO CAUTELAR

21. A través del escrito de fecha 9 de enero de 2024, con sumilla: "SOLICITO INICIO DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA Y SE DICTE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR", subsanado a través del escrito de fecha 10 de enero de 2024, con sumilla: "SUBSANO OBSERVACIONES Y OTROS", el Contratista solicitó la concesión de una medida cautelar de no innovar a efectos de que se ordene a la Entidad se abstenga de ejecutar las siguientes cartas fianzas:

i) La Carta Fianza N° E0642-02-2023, emitida por Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantía, por el monto de S/. 531,888.70, como garantía de adelanto de materiales correspondiente a la Adjudicación Simplificada Nº 001-2022-MDSSSQ/CS;

ii) La Carta Fianza E4471-01-2022, emitida por Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantía, por el monto de S/. 279,972.98, como garantía de fiel cumplimiento del contrato correspondiente a la Adjudicación Simplificada Nº 001-2022-MDSSQ/CS y;

iii) La Carta Fianza E4477-03-2022, emitida por Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantía, por el monto de S/ 220,764.25, como garantía por el adelanto directo correspondiente a la Adjudicación Simplificada Nº 001-2022-MDSSQ/CS."

SOBRE LA FUTURA PRETENSIÓN A CAUTELAR

22. El Contratista ha señalado que, el futuro proceso arbitral tendrá como pretensión la siguiente:

> "Que, el Tribunal Arbitral DECLARE QUE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO No 009-2022-MDSSQ/UA efectuada por la Municipalidad Distrital de San Salvador de Quije mediante Resolución de Alcaldía No 110- 2023-MDSS/A de fecha 27 de octubre de 2023, ES NULA, INVÁLIDA E INEFICAZ."

SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL PEDIDO CAUTELAR

23. Como sustento de su pedido cautelar, el Contratista señala lo siguiente:

Verosimilitud del derecho: indebida resolución del contrato

24. Señala que, si bien el artículo 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, el RLCE) estipula la facultad de la Entidad de aplicar penalidades ante demoras injustificadas; y además, el artículo 164 del mismo RLCE señala que la Entidad se encuentra habilitada a resolver el contrato por acumulación máxima de penalidades u otras causas; no es menos cierto que esta facultad se encuentra regulada también, por el Contrato y las Bases Integradas, que son vinculantes para las partes.

25. En ese sentido, manifiesta que, la resolución del contrato por acumulación máxima de penalidades será indebida (y por lo tanto invalida e ineficaz), si es que la Entidad no ha seguido el procedimiento (establecido en las Bases Integradas) para calcular las penalidades.

26. Indica que, las Bases del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2022-MDSSQ/CS – PRIMERA CONVOCATORIA, ha establecido el procedimiento para la aplicación de OTRAS PENALIDADES.

27. Así, manifiesta que, en el numeral 30 del CAPITULO III "REQUERIMIENTO" de las Bases del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA No 001-2022-MDSSQ/CS PRIMERA CONVOCATORIA, la Entidad ha establecido la aplicación de OTRAS PENALIDADES (distintas a la mora). Para tal efecto, indica que, la Entidad ha previsto que estas sean (i) objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; (ii) ha definido los supuestos que originarían su aplicación; (iii) ha delimitado la forma en la que se debe calcular la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente definió y; (iv) ha establecido el procedimiento a través del cual se verifica la configuración del supuesto que da lugar a la aplicación de otras penalidades.

28. Sin embargo, señala que, tanto de la Resolución de Alcaldía N° 110-2023- MDSSQ/A de fecha 27 de octubre de 2023, como del Informe N° 229-2023- MDSSQ-ESNH/SGIDUR/AECM de fecha 20 de octubre de 2023 (que sirve para la fundamentación de la primera) se puede dilucidar o advertir que la Entidad no ha seguido el procedimiento establecido en las Bases (numeral 38 de CAPÍTULO III REQUERIMIENTO) para verificar la configuración del supuesto que da lugar a la aplicación de otras penalidades.

29. De acuerdo con ello, concluye que, la Entidad no ha seguido el procedimiento para verificar la configuración del supuesto que da lugar a la aplicación de otras penalidades, establecido en las BASES y, por lo tanto, desconoce como es que la Entidad llegó a la conclusión de que se ha computado la penalidad máxima.

30. En ese sentido señala que, si no se ha seguido el procedimiento, no se puede configurar una causal de penalidad y, por lo tanto, no se puede computar una penalidad.

31. Finalmente, manifiesta que, si bien el artículo 164, numeral 164, literal b) y el artículo 165, numeral 165.4 del RLCE facultan a la Entidad a resolver el contrato cuando se configura una acumulación máxima de

penalidades; esta causal solamente será aplicable si, en efecto, se verifica la acumulación máxima de penalidades, lo cual, según señala, no habría sucedido en el presente caso.

Peligro en la demora y perjuicio irreparable:

32. Señala que, la Carta Fianza N° E0642-02-2023, Carta Fianza E4471-01-2022 y Carta Fianza E4477-03-2022, tienen la naturaleza fianza solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible y de realización automática; esta puede ser ejecutada en cualquier momento. Por lo tanto, el peligro en la demora radica esencialmente en la posibilidad que tiene la Entidad puede ejecutar dichas fianzas, sin necesidad de esperar la conclusión del proceso arbitral (peligro en la demora); a pesar, de que la resolución del contrato efectuado por la Entidad carece de sustentos facticos y jurídicos.

33. Este peligro, indica, no solamente es expectaticio, posible o probable; sino un peligro real e inminente, pues, conforme se tiene de las Carta Notarial N° 002-2024- MDSSQ/A (Carta Fianza N° E9642-02-2023), Carta Notarial N° 003-2024- MDSSQ/A (Carta Fianza N° E4471-01-2022) y, Carta Notarial N° 001-2024- MDSSQ/A (Carta Fianza N° E4477-03-2022); la Entidad ha solicitado la ejecución de las fianzas materia de tutela cautelar.

34. En ese contexto, indica, se tiene que una vez ejecutada las cartas fianza, estas serán de difícil restitución y, además, al ser ejecutadas serán de libre disposición de la Entidad y, finalmente, al sumar las fianzas un total de S/ 1’032,624.93, constituiría una grave afectación a la estabilidad económica del Contratista, generando así, un daño irreparable.

Razonabilidad, proporcionalidad y adecuación:

35. Expresa que, la medida es razonable, por cuanto el derecho que se busca cautelar es la vigencia de un contrato estatal y, conexamente, la conservación de las cartas fianzas (que garantizan el fiel cumplimiento del contrato, el adelanto directo y el adelanto para materiales). Este derecho, si bien tiene una manifestación legal en los artículos 164, numeral 164, literal b) y el artículo 165, numeral 165.4 del RLCE, tiene también un núcleo constitucionalmente protegido, que se encuentra instituido en el artículo 59 de la Constitución, que señala: “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivos a la moral, ni la salud, ni la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que

sufren cualquier desigualdad, en tal sentido, promueve la pequeña empresa en todas sus modalidades".

36. En suma, concluye que, el derecho que busca proteger con la petición cautelar, es un derecho constitucionalmente protegido.

37. Y por último, señala que la medida cautelar es proporcional, por cuanto la finalidad perseguida (vigencia del Contrato y conservación de las cartas fianzas) solamente puede ser protegido mediante una medida cautelar (adecuada), debido a que la Entidad ya ha iniciado los trámites para la ejecución de las fianzas. Asimismo, la medida cautelar de no innovar, es la única que garantiza que la Entidad no altere el estatus quo; es decir, que no ejecute las fianzas. No existe otra medida cautelar que cumpla esta finalidad (necesidad). Finalmente, la medida es proporcional en sentido estricto, pues el derecho conculcado a la Entidad recibe una mínima lesión, pues las fianzas seguirán vigentes (por mandato legal y, si se quiere, arbitral) y, en contraposición, el derecho que se busca proteger tiene una alta satisfacción, pues el Contratista no se verá afectado en ninguna medida, más que en los gastos procesales.

Contracautela:

38. Señala que, ofrece contracautela en la forma de Caución Juratoria hasta por el monto de S/. 20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles); no obstante, indica que, deja a criterio del Árbitro de Emergencia, la decisión de exigir otra forma de contracautela.

39. En lo que concierne a la modificatoria del numeral 2 del artículo 8 de la Ley de Arbitraje por medio de Decreto de Urgencia 20-2020, incluyendo un segundo párrafo a dicho artículo, el cual establece que, en los casos en los que el Estado peruano es parte afectada con la medida cautelar se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral precisándose que el monto de la garantía no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento, solicita que, al vulnerarse derechos constitucionales tales como el de igualdad y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, rogamos al Árbitro de Emergencia que (en el marco del reconocimiento establecido en el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en el Exp. 142-2011-PA/TC), hacer control difuso y establecer que no corresponde exigir para el caso concreto la fianza bancaria y/o patrimonial señalada en la norma que se inaplica (Decreto de Urgencia N° 20-2020).

B. POSICIÓN DE LA ENTIDAD

SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR

40. Como sustento de su oposición al pedido cautelar, la Entidad señala lo siguiente:

Verosimilitud del derecho:

41. Señala que, haciendo una mera lectura de los fundamentos expuestos en la solicitud cautelar y los medios de prueba ofrecidos, se podrá verificar que la resolución del contrato motivada por el incumplimiento de las obligaciones del Contratista que han generado la acumulación máxima de penalidades por ausencia de permanencia del personal del plantel profesional clave propuesto, es válida y eficaz; y, por lo tanto, la decisión de resolver el contrato se declarará procedente; pues, en ningún momento la empresa ha negado la imputación de incumplimiento de obligaciones sino, solamente se ha referido a una supuesta falta de cumplimiento del procedimiento establecido, por parte de la Entidad, para verificar la configuración del supuesto que da lugar a la aplicación de otras penalidades; sin embargo, conforme se acredita con la Carta N° 072-2023- CONSORCIOQORIMAYO/VAMA-RL más anexos, Carta N° 076-2023- CONSORCIOQORIMAYO/VAMA-RL más anexos, tomas fotográficas y demás documentos adjuntos, la Entidad ha demostrado el incumplimiento de las obligaciones de la Contratista, ha seguido estrictamente el procedimiento establecido, ha realizado el cálculo de penalidades de manera objetiva y las ha puesto en conocimiento de la empresa oportunamente, quien en respuesta a los requerimientos de la Entidad ha osado presentar constancias fraudulentas, con el objetivo de aparentar la presencia del personal clave; sin embargo, las mismas autoridades que suscribieron las actas se retractaron de su contenido y manifiestan fueron sorprendidos para su suscripción, conforme puede apreciarse del acta de retracto adjunto a la presente.

42. Por otro lado, señala que, en cuanto a las cartas fianzas de garantía por adelanto directo y de materiales, el literal c) del Artículo 155° del Reglamento de la LCE establece taxativamente lo siguiente:

> "d) La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realice la amortización o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversias."

43. Es decir, indica, al margen de la instalación de un proceso arbitral por la controversia, la garantía por adelantos siempre sí debe ejecutarse, dado que la empresa contratista a la fecha no ha realizado la amortización o pago, pese a habérselo requerido notarialmente y adicionalmente porque la decisión declarativa que se vaya a emitir en el proceso principal no tiene vinculación alguna con la obligación de la empresa de devolver los adelantos otorgados.

44. En este contexto y a modo de conclusión, señala que, a lo largo de su exposición, el Contratista justifica el incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales por la supuesta falta de cumplimiento del procedimiento para el requerimiento de la entidad, inobservando de esta manera los principios básicos de la buena fe contractual y procesal, pues a través de la presente medida quiere desvincularse de sus obligaciones generando un peligro real para la Entidad de perder el presupuesto otorgado como adelanto, orientado al cumplimiento de sus fines, metas y objetivos, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público.

45. En consecuencia, concluye que, habiendo quedado desvirtuado el presupuesto de la verosimilitud del derecho, no corresponde otorgar la medida cautelar solicitada.

Peligro en la demora:

46. Indica que, este supuesto está referido a la amenaza de que el proceso arbitral se torne ineficaz durante el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación procesal hasta el pronunciamiento definitivo en un Laudo generándose el peligro de ocasionar un daño; sin embargo, reiteramos que la ejecución de las cartas fianzas no tienen injerencia sobre la ejecución del laudo declarativo que promueve el contratista; y que, por el contrario, de otorgarse la medida cautelar solicitada se materializaría el riesgo que la Entidad enfrenta de no poder recuperar los adelantos otorgados.

Proporcionalidad:

47. Respecto a este requisito, señala que, la medida cautelar debe ser coherente, congruente y proporcional con lo que se desea asegurar, velando también por una mínima injerencia negativa sobre los intereses del afectado con la medida; ya que, como bien lo ha expuesto Roxana Jiménez Vargas-Machuca en sus apuntes sobre Medidas Cautelares, debe resaltarse la importancia de este requisito: ...pues incide en la prevención de medidas cautelares ilícitas, por cuanto su inobservancia

"distorsiona la finalidad de las medidas, convirtiéndolas, en muchas ocasiones, en mecanismos de presión psicológica o medios para obtener una tutela satisfactiva".

Contracautela:

48. Expresa que, la contracautela es un instrumento que sirve para restaurar el equilibrio perdido al otorgarse la medida y tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de lo daños y perjuicios que pueda causar su ejecución; por ello, la obligación de presentarla como requisito para otorgar la medida cautelar, conforme lo estipulado en el artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 020-2020 DECRETO DE URGENCIA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1071, DECRETO LEGISLATIVO QUE NORMA EL ARBITRAJE.

    Sin embargo, señala que, el Contratista solicita hacer control difuso para no exigir la fianza bancaria como contracautela, y al respecto precisamos que el Tribunal Constitucional ha establecido parámetros constitucionales que cualquier órgano jurisdiccional, incluido el arbitral, debe cumplir para ejercer válidamente este tipo de control, y estos son:

    - El control difuso debe realizarse en armonía con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

    - La norma objeto de control debe ser relevante para la solución del caso y suponer un potencial perjuicio, claro y directo, para alguna de las partes.

    - El control difuso es residual: se debe inaplicar la norma incompatible con la Constitución solo si no es posible reconducirla a través de la interpretación constitucional.

    - El control difuso requiere aplicar el test de ponderación.

49. Por último, la Entidad solicita que el Árbitro de Emergencia disponga la ejecución de las cartas fianzas de fiel cumplimiento y de adelantos por el saldo pendiente de pago según al siguiente detalle:

    1. N° E4471-01-2022 de fiel cumplimiento por la suma de S/279,971.98.

    2. N° E4471-03-2022 por adelanto directo por la suma de S/220,764.25, precisando que éste es el monto de la última renovación; sin embargo, aún está pendiente de amortización la suma de S/245,869.50; y,

3. N° E0642022023-001 por adelanto de materiales por la suma de S/528,918.44

C. POSICIÓN DEL ÁRBITRO DE EMERGENCIA

50. Para conceder la petición cautelar, es necesario verificar la concurrencia de los presupuestos exigidos: (i) la verosimilitud del derecho invocado; (ii) peligro la demora del proceso; y, (iii) la razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión; y para su ejecución, es necesario cumplir con la (iv) contracautela.

51. La primera condición, esto es la verosimilitud del derecho invocado, el "fumus boni iuris" o "humo del buen derecho" consiste en la apariencia del derecho legítimo. La verosimilitud no sugiere que el Tribunal Arbitral evalúe si la pretensión es o no fundada, sino que considere, por lo menos, que la pretensión tiene un sustento jurídico que la hace discutible, de modo que un derecho es verosímil cuando reviste apariencia de verdadero.

52. Como explica MONROY GALVEZ "advertido entonces que el peticionante de una medida cautelar únicamente necesita acreditar la apariencia de su derecho, resulta interesante describir cuál debe ser la conducta del juez ante tal petición. En nuestra opinión, al analizar la prueba en torno a la verosimilitud del derecho invocado, el juez debe realizar una estimación, diríamos mejor, un cálculo de probabilidades que le permita persuadirse que el derecho cuya cautela se pide, existe, en principio"[1].

53. Cabe resaltar que la evaluación de la verosimilitud en el derecho y su acreditación a criterio de este Árbitro Único para la concesión de una medida cautelar, no implica, en ningún caso, un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia, toda vez que, esta será analizada en el proceso arbitral y finalmente resuelta en el laudo por el Tribunal Arbitral, colegiado o unipersonal, que se constituya.

54. La segunda condición para otorgar una medida cautelar, el peligro real en la demora y la inminencia de un perjuicio irreparable (periculum in mora) constituye - a juicio de la doctrina - el presupuesto más importante del pedido cautelar.

[1] Monroy Palacios, Juan. *Temas de Proceso Civil*, Studium, Lima, 1987, p. 26.

55. Según CALAMANDREI, el peligro en la demora es "el interés específico que justifica la emanación de cualquiera de las medidas cautelares"[2].

56. Definiendo este concepto, MONROY PALACIOS ha señalado que "El periculum in mora está referido a la amenaza de que el proceso se torne ineficaz durante el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación procesal hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Su existencia no está sustentada necesariamente en la posibilidad de que actos naliciosos del demandado impidan el cumplimiento de lo pretendido por el demandante, sino también en que el solo transcurso del tiempo constituye, de por sí, un estado de amenaza que merece una tutela especial"[3].

57. En cuanto a la razonabilidad, se debe analizar la adecuación de la medida cautelar para los fines que ha sido solicitada. Conforme señala ANA MARÍA ARRARTE "la adecuación, que implica que las medidas cautelares sean congruentes y proporcionales con el objeto que es materia de tutela, es decir con las pretensiones planteadas en la demanda"[4].

58. Por último, la contracautela se erige como una garantía para el afectado con la medida cautelar ante los daños y perjuicios que podría sufrir al soportar la misma.

59. A continuación, procederemos a evaluar si en el presente caso se cumple con los presupuestos antes señalados, no sin antes referirnos al cuestionamiento de la falta de instrumentalidad señalada por la Entidad, toda vez que, desde su posición, la ejecución de las cartas fianzas no tienen injerencia alguna sobre la eficacia práctica del laudo, pues en este solo se emitirá un pronunciamiento declarativo sobre la supuesta nulidad, invalidez e ineficacia de la resolución del contrato, quedando desvirtuada la instrumentalidad de esta medida cautelar y su subordinación respecto al proceso principal.

ANÁLISIS SOBRE LA INSTRUMENTALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR

60. Del pedido cautelar presentado y de la posición sustentada por ambas partes, tanto a través de sus escritos de medida cautelar así como el de

---

[2] Calamandrei, Piero. "Introducción al estudio sistemático de las medias cautelares", El Foro, Buenos Aires, 1996, p.40.
[3] Monroy Palacios, Juan José. "Bases para la formación de una teoría cautelar", Comunidad, Lima, 2002, p.176.
[4] Arrarte, Ana María. Apuntes sobre las medidas cautelares en el sistema arbitral peruano. En: Revista Peruana de Arbitraje N° 7, Lima, 2008, pp. 128-129.

oposición a la misma, y lo informado en la audiencia especial, se advierte lo siguiente:

- Debemos tener presente que, en estos momentos, el Contrato se encuentra resuelto, toda vez que, mediante la Carta Notarial N° 011-2023-MDSQQ/A de fecha 27 de octubre de 2023, la Municipalidad Distrital de San Salvador de Quije (en adelante, la ENTIDAD) comunicó al CONTRATISTA la resolución del Contrato N° 009-2022-MDSSQ/UA de fecha 27 de diciembre de 2022, para la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego en la Localidad de Lluchcanta, del Distrito de San Salvador de Quije – Provincia De Sucre – Departamento de Ayacucho" (en adelante, el Contrato).

- El hecho de que el Contrato se encuentre resuelto despliega determinados efectos, como son la ejecución de que el CONTRATISTA, conforme lo establece el artículo 155 del RLCE:

  "Artículo 155. Ejecución de garantías

  155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:

  a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por el adelanto pendiente de amortización.

  b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

  c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de

conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en la liquidación final del contrato, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

d) La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realice la amortización o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversias.

155.2. En cualquiera de los supuestos contemplados en el numeral anterior, la Entidad en forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere notarialmente al contratista, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto.

155.3. Los supuestos previstos en los numerales anteriores están referidos exclusivamente a la actuación de la Entidad, siendo de su única y exclusiva responsabilidad evaluar en qué supuesto habilitador se encuentra para la ejecución de la garantía, por lo que no afectan de modo alguno al carácter automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de pago a cargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley, al solo y primer requerimiento de la respectiva Entidad, sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin oponer excusión alguna y sin solicitar sustento ni documentación alguna y en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles. Cualquier pacto en contrario contenido en la garantía emitida es nulo de pleno derecho y se considera no puesto, sin afectar la eficacia de la garantía extendida."

- Conforme se aprecia, la resolución contractual practicada por la Entidad puede dar lugar a que esta ejecute las cartas fianzas otorgadas como garantías de fiel cumplimiento y de adelantos directo y de materiales; en ese sentido, si bien la materia en controversia del arbitraje iniciado por el Contratista tratará sobre la resolución contractual, este Árbitro de Emergencia no puede soslayar que la legalidad de tal acto resolutivo será revisada por el Tribunal Arbitral, colegiado o unipersonal, que se constituya en el

proceso arbitral; por tanto, lo peticionado por el Contratista se encuentra íntimamente vinculado con la pretensión demandada.

- En efecto, lo que el Contratista busca es que a raíz del acto que será materia de revisión en el proceso arbitral no se ejecuten actos que le genere un perjuicio, como lo sería la ejecución de las cartas fianzas de garantía de fiel cumplimiento y de adelantos directo y de materiales, más aún cuando dicho acto no ha quedado consentido y, como mencionamos, ha sido sometido a arbitraje.

- De ahí se aprecia con suma claridad la vinculación e intrumentalidad entre la medida cautelar solicitada y el proceso principal, puesto que, en el hipotético caso de que al emitirse el laudo este le sea favorable al Contratista, este será eficaz y no se verá perjudicado por la realización de actos en virtud de la resolución del contrato a que se habría llevado a cabo.

61. Teniendo en cuenta lo mencionado, se desestima el argumento de la Entidad sobre la falta de instrumentalidad de la medida cautelar solicitada.

ANÁLISIS SOBRE LA VEROSIMILITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR

62. Ahora bien, a continuación iniciaremos el examen de la verosimilitud del derecho, recordando siempre que, este presupuesto no importa llegar a un nivel de convicción pleno del derecho reclamado por el Contratista, sino, únicamente basta que exista cierta apariencia o probabilidad de que la pretensión del Contratista tendrá éxito, es decir, será amparada.

63. Conforme se advierte, la pretensión que planteará el Contratista y que se ventilará en el proceso arbitral tiene por objeto que se declare la nulidad, invalidez e ineficacia de la resolución contractual practicada por la Entidad, la cual se encuentra sustentada en la acumulación máxima de penalidades por ausencia de permanencia del personal del plantel profesional clave propuesto.

64. Por su parte, la Entidad ha manifestado que la resolución del contrato es válida y eficaz, pues, según indica, conforme lo acredita con la Carta N° 072-2023- CONSORCIOQORIMAYO/VAMA-RL más anexos, Carta N° 076-2023- CONSORCIOQORIMAYO/VAMA-RL más anexos, tomas fotográficas y demás documentos adjuntos, ha demostrado el incumplimiento de las obligaciones de la Contratista, ha seguido estrictamente el procedimiento establecido, ha realizado el cálculo de penalidades de manera objetiva y las ha puesto en conocimiento de la empresa oportunamente, quien en respuesta a los requerimientos de la

Entidad ha osado presentar constancias fraudulentas, con el objetivo de aparentar la presencia del personal clave; sin embargo, las mismas autoridades que suscribieron las actas se retractaron de su contenido y manifiestan fueron sorprendidos para su suscripción, conforme puede apreciarse del acta de retracto adjunto a la presente.

65. En ese sentido, la litis radica en si la Entidad cumplió o no el procedimiento para la aplicación de penalidades; por lo que, corresponde verificar a nivel de verosimilitud del derecho si ello ha sucedido.

66. Conforme lo establece el inciso 138.1 artículo 138 del RLCE, "El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes."

67. Entre los documentos del procedimiento de selección, se encuentran las Bases Integradas que, conforme lo establece el Anexo N° 1 "Definiciones" del RLCE, es el "Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Simplificada cuyo texto incorpora las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, según sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones, ni se hayan realizado acciones de supervisión."; es decir, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y, en consecuencia, de la relación contractual que se perfeccione en virtud de esta última.

68. Atendiendo a ello, tenemos que, en la cláusula Décima Quinta del Contrato, se pactó la aplicación de penalides, entre las cuales se encuentra la siguiente:

Otras penalidades			
N°	**Supuesto de aplicación de penalidad**	**Forma de cálculo**	**Procedimiento**
1	*Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.*	*0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto*	*Según informe del supervisor de Obra.*
2	*En caso el contratista incumpla con su*	*0.50 UIT*	

69. Por su parte, en las Bases Integradas se estableció lo siguiente:

Procedimiento para aplicación de penalidad:

1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción.
2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.
3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).
4. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y mediante carta comunica a la ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente valorización.
5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad

70. Conforme se advierte, de lo regulado en las Bases Integradas y el Contrato, para la aplicación de penalides, la Entidad debía seguir el procedimeinto ahí establecido; sin embargo, de lo expresado por la Entidad y de las Cartas N° 072-2023- CONSORCIOQORIMAYO/VAMA-RL más anexos, N° 076-2023- CONSORCIOQORIMAYO/VAMA-RL más anexos que se adjuntan, no puede apreciarse y verificarse el cumplimiento del procedimiento establecido, toda vez que, de ellos si bien se aprecia la información remitida por la Supervisión de la Obra, no se aprecia así que se haya seguido con el procedimiento establecido, lo cual será materia de pronunciamiento final por parte del Tribunal Arbitral, donde las partes con mayor amplitud probatoria podrán generar convicción plena sobre si se ha cumplido o no con el procedimiento exigido en las Bases Integradas y el Contrato.

71. Atendiendo a ello, a nivel de verosimilitud del derecho, esta Árbitro de Emergencia considera que no se ha cumplido con el procedimiento establecido para la aplicación de penalidades, sustento principal y único de la resolución del contrato.

ANÁLISIS SOBRE EL PELIGRO EN LA DEMORA

72. En el presente caso, no es un hecho controvertido que, la Entidad ha remitido a SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA, las Cartas Notariales N° 001-2024-MDSSQ-/A, N° 002-2024-MDSSQ-/A, N° 003-2024-MDSSQ-/A, solicitando que la ejecución de las cartas fianzas E4477-03-2022, E0642-02-2023 y E4471-01-2022, respectivamente.

73. En ese sentido, al haber solicitado a SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA la ejecución de las cartas fianzas E4477-03-

2022, E0642-02-2023 y E4471-01-2022, conforme al numeral 33.3 del artículo 33 del TUO de la Ley de Contrataciones con el Estado, en virtud de la realización automática que caracteriza a esto instrumentos de garantía, dicha institución cuenta con un plazo de 3 días para que abone los montos requeridos; por tanto, queda claro que existe un riesgo latente de que por la duración del proceso arbitral la Entidad ejecute las cartas fianzas entregadas como garantías de fiel cumplimiento y adelantos directo y de materiales.

74. Agregado a ello, debe tenerse presente que, el literal el artículo 155 del RLCE, establece lo siguiente:

> "Artículo 155. Ejecución de garantías
>
> 155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:
>
> (…)
> b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
>
> (…)
>
> d) La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realice la amortización o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversias.
>
> 155.2. En cualquiera de los supuestos contemplados en el numeral anterior, la Entidad en forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere notarialmente al contratista, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto."

75. Conforme se aprecia, para la ejecución de las garantía de fiel cumplimiento es necesario que la resolución del Contrato haya quedado consentida; sin embargo, en el presente caso, ambas partes tienen conocimiento de que ello no ha sucedido dado que existe un proceso

arbitral en donde la resolución del contrato practicada por la Entidad se encuentra sometida a arbitraje, tal como lo manifestó la Entidad en respuesta a la pregunta del Árbitro de Emergencia, efectuada en el minuto 01:13:03 del video de la Audiencia Especial.

76. Asimismo, según la disposición en comento, para la ejecución de las garantías de adelantos directo y de materiales, se requiere que no se haya realizado la amortización o el pago; sin embargo, esto tampoco ha sido acreditado, dado que no se advierte que exista requerimiento notarial previo para la ejecución de dichas garantías -así como tampoco para la de fiel cumplimiento- por el plazo de diez (10) días hábiles, más aun cuando la Entidad, ante la pregunta efectuada por el Árbitro de Emergencia, sobre si hubo requerimiento notarial previo al Contratista, esto es, antes de remitir el requerimiento de ejecución de las garantías a la compañía aseguradora, señaló que no hubo, conforme puede apreciarse del minuto 01:22:21 del video de la Audiencia Especial.

77. En ese contexto, se cumple con el presupuesto de peligro en la demora, necesario para la concesión de una medida cautelar.

ANÁLISIS SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA MEDIDA

78. En el punto anterior ha quedado claro que existe riesgo de la ejecución de las cartas fianzas otorgadas como garantías de fiel cumplimiento y por adelantos.

79. Ahora bien, la concesión de una medida cautelar también requiere que se cumplacon el requisito de la adecuación, y esto quiere decir, analizar si la medida que sepide se condice con el derecho que se pretende tutelar en el arbitraje principal. Asimismo supone, siempre decidir por la medida menos gravosa, es decir, aquellaque tutelando el derecho cause menos daño a la contraparte.

80. Dicho esto, tenemos que el Tribunal Arbitral que resulte competente pararesolver la controversia principale, tendrá el encargo de resolver la siguiente pretensión:

> "Que, el Tribunal Arbitral DECLARE QUE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO No 009-2022-MDSSQ/UA efectuada por la Municipalidad Distrital de San Salvador de Quije mediante Resolución de Alcaldía No 110- 2023-MDSS/A de fecha 27 de octubre de 2023, ES NULA, INVÁLIDA E INEFICAZ."

81. Esto quiere decir, que tendrá el encargo de evaluar, si efectivamente, se cumplieron con el supuesto para la resolución del Contrato; es decir,

si la resolución del Contrato fue válida o no, y dentro de este análisis establecer si la aplicación de la penalidad cuya acumulación máxima gatilló la resolución del contrato, siguió el procedimiento establecido.

82. En este sentido, la medida solicitada por el Contratista respecto a que se disponga la no ejecución de las cartas fianzas por adelantos resulta una medida adecuada, toda vez que, la ejecución de estas garantías se realiza frente a la resolución contratual por acumulación máxima de penalidad, y esto supone, aunque parezca redundante, que la aplicación de dicha penalidad "efectivamente" sea válida, todo lo cual deberá ser dilucidado por el Tribunal Arbitral que resulte competente.

83. Igualmente, resulta ser la medida menos gravosa, considerando que que las cartas fianzas por garantías de fiel cumplimiento y por adelantos deberán ser renovadas permanentemente por el Contratista, para que la Entidad no quede desprotegida ante el laudo definitivo, en caso le diera la razón.

SOBRE LA CONTRACAUTELA

84. Respecto de la contracautela, el Contratista ofreció contra cautela en forma de Caución Juratoria hasta por el monto de S/ 20,000 (Veinte mil y 00/100 soles), dejando a salvo que esta Árbitro de Emergencia decida si corresponde emitir otra forma de contracautela.

85. Asimismo, dicha parte refirió que, la aplicación de la modificatoria del numeral 2 del artículo 8 de la Ley de Arbitraje efectuada a partir del contenido del Decreto de Urgencia Nº 20-2020, estableció que en los casos en los que el Estado peruano es parte afectada con la medida cautelar se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la Entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral precisando que el monto de la garantía no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento; extremo que debe considerar lo siguiente:

i) Su cumplimiento implicaría que la Entidad tenga un doble garantía y se estaría condicionando a la empresa a la concesión de una medida cautelar.

ii) El Tribunal Constitucional estableció que "(…) la igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2 de la Constitución, de acuerdo al "(…) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica

o de cualquier otra índole". Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, se está frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino en ser tratado del mismo modo que quienes se encuentren en una idéntica situación". Exp. Nº 2835-2010-PA/TC,fj.385.

iii) El respeto por el derecho a la igualdad, por el que un órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable; por lo que, las normas deben ser aplicadas por igual.

iv) De la exposición de motivo del Decreto de Urgencia Nº 20-2020, consideran que existe una abusiva utilización de medidas cautelares por parte de los Consorcio y/o empresas contratistas, cuyo otorgamiento genera consecuencias negativas para el Estado, como: paralización de la ejecución de la obra, afectación en la prestación de los servicios públicos, etc.

v) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que en palabras del Tribunal Constitucional se aduce que "(…) la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañársele a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante sentencia, resulte eficazmente cumplida. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el orden dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia" Exp. Nº 76-2005-PA/TC, fj. 06.

vi) El derecho a la tutela jurisdiccional debe prevalecer por sobre lo que consideran, una traba ilegal contenida en el Decreto de Urgencia Nº 20-2020.

vii) Por considerar que la norma aludida vulnera derechos constitucionales, solicitan que en el marco del precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº

142-2011-PA/TC, se realice control difuso y se establezca que no corresponde exigir para el caso concreto la fianza bancaria y/o patrimonial exigida en el Decreto de Urgencia Nº 20-2020.

86. Por su parte, la Entidad en su escrito de oposición a la medida cautelar en relación a los argumentos relacionados a la contracautela ha manifestado lo siguiente:

    i) La Contracautela es un instrumento que sirve para restaurar el equilibrio perdido al otorgarse la medida cautelar.

    ii) El artículo 8 del Decreto de Urgencia Nº 20-2020 establece como una obligación la presentación de contracautela a partir de la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solicidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la Entidad.

    iii) De acuerdo al Tribunal Constitucional, el control difuso debe cumplir ciertos parámetos: a) Debe realizarse en armonía con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; b) Debe ser relevante para la solución del caso y suponer un potencial perjuicio, claro y directo, para alguna de las partes; c) Es residual; d) Requiere aplicar el test de ponderación.

87. Estando a lo mencionado por ambas partes, es preciso mencionar que la contracautela o caución es "la garantía que ofrece el solicitante de una medida cautelar con la que respalda el pago de una eventual indemnización de daños y perjuicios al que se pudiera ver obligado, en caso la medida cautelar[5] obtenida haya sido ejecutada indebidamente".

88. Este Árbitro de Emergencia tiene en cuenta que la Entidad ha invocado la aplicación de la modificación al artículo 8 del Decreto Legislativo que norma el arbitraje (en adelante, Ley de Arbitraje), efectuada mediante el Decreto de Urgencia 020-2020 y, por su parte, el Consorcio ha invocado su no aplicación bajo la aplicación de un control difuso.

89. Sobre el particular, el artículo 109 de la Constitución Política del Perú establece que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

90. Por su parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna se ordena que: "(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se

[5] PRIORI POSADA, Giovanni. La tutela cautelar. Su configuración como derecho fundamental. Ara: Lima, 2006, p. 76

aplica a las consecuencias de las relaciones existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad (...)".

91. A la fecha de emisión de la presente Decisión, este Árbitro de Emergencia no ha tomado conocimiento que lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 020-2020 haya sido derogado por una norma posterior ni tampoco que se haya publicado algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de lo regulado en el citado dispositivo.

92. Por otro lado, se tiene que la Comisión de Justicia de Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú ha concluido mediante Dictamen que el Decreto de Urgencia 020-2020, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje cumple con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú[6].

93. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, en mayoría, lo regulado en el Decreto de Urgencia Nº 20-2020 se encuentra vigente y es de aplicación al presente incidente cautelar al ser una norma de carácter procesal que regula el requisito de la contracautela en los arbitrajes en contrataciones con el Estado.

94. Ahora bien, de la revisión de la parte considerativa del Decreto de Urgencia No 20-2020 se aprecia que la norma fue dictada para "fortalecer la institución del arbitraje y evitar la proliferación en los que las malas prácticas resten eficacia al arbitraje y causen graves perjuicios al Estado peruano". En ese sentido, prima facie, la finalidad que enuncia la norma resultaría ser válida en tanto trata de evitar la generación de graves perjuicios en detrimento del Estado.

95. Dicho esto, si nos remitimos a la modificatoria del artículo 8 de la Ley de Arbitraje se han establecido nuevos requisitos al regular la contracautela para las medidas cautelares otorgadas en el marco de arbitrajes en contrataciones con el Estado es la siguiente:

> "Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial
> 2. (...) En los casos los que el Estado peruano es la parte

[6] CIRCULO DE ARBITRAJE CON EL ESTADO. Comisión de Justicia y Derechos Humanos concluye en que el Decreto de Urgencia 020-2020, cumple con lo establecido en segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú. Lima, 24 de febrero de 2022. Véase en: https://www.caeperu.com/noticias/comision-de-justicia-y-derechos-humanos-concluye-en-que-el- decreto-de-urgencia-020-2020.html

afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la **presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral.** El monto de la contracautela lo establece el/la juez o el tribunal arbitral ante quien se solicita la medida cautelar, **dicho monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento.** La ejecución de la carta fianza se establece conforme a lo resuelto por el/la juez/a o el tribunal arbitral, según corresponda." (Énfasis agregado)

96. Se aprecia que la norma en cuestión regula un supuesto de hecho, el cual es el que una Entidad estatal sea la parte afectada con una medida cautelar y se establece como consecuencia jurídica la obligación del juez y/o tribunal arbitral de exigir al solicitante de la medida cautelar la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial que cumpla con las siguientes características: ser solidaria, incondicionada y de realización automática a favor de la Entidad. Adicionalmente, la norma ordena que el monto de dicha garantía no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento y debe encontrarse vigente por el tiempo que dure el proceso arbitral.

97. En este punto, conviene evaluar la solicitud del Contratista para que se inaplique el artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 20-2020 para el caso concreto vía el control difuso.

98. El control difuso se ejerce por el árbitro al momento de resolver una controversia en el supuesto en el que considere que, habiendo intentado realizar una interpretación de las disposiciones, no sea posible que coexista con la norma constitucional, en este caso, la modificación del artículo 8 del Decreto N° 1071 por el Decreto de Urgencia Nº 20-2020.

99. Ahora bien, este Árbitro de Emergencia tiene presente que el Tribunal Constitucional ha establecido reglas para el ejercicio del control difuso sobre normas de rango legal en un arbitraje. Por ello, resulta relevante traer a colación lo determinado por el Tribunal Constitucional en el Expediente No 0142-2011-AA/TC, el cual menciona lo siguiente:

> "26. (....) El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia vinculante dictada por este Tribunal Constitucional sobre el control difuso. **Sólo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre**

que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes"[7].

100. Bajo estas consideraciones, es necesario para el adecuado ejercicio de control difuso que (i) no sea posible obtener una interpretación de la norma conforme a la Constitución y (ii) se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes, que en este caso podría ser el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del Contratista.

101. La tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que permite a los particulares acceder al sistema de justicia a fin de que vean amparados sus reclamos de ser el caso.

102. A consideración de este Árbitro de Emergencia, si bien puede considerarse que el requerimiento de una carta fianza por un monto equivalente al de la garantía de fiel cumplimiento constituye una carga económica significativa para el Contratista al momento de solicitar y/o mantener una medida cautelar que afecte a los intereses del Estado, esta situación no constituye por sí misma una limitación absoluta al derecho a la tutela cautelar, puesto que cabría la posibilidad de que el beneficiario de la medida cautelar cuente con el respaldo económico suficiente para poder acceder a esta garantía y se pueda dar cumplimiento a la exigencia de la normativa vigente.

103. Si bien el demandante ha alegado que el requerir al Contratista una contracautela en el sentido que pretende el dispositivo en análisis representaría tener una doble garantía y que podría generarle daños y perjuicios al Contratista, no se advierte que se haya acreditado la imposibilidad real de acceder a la garantía exigida por la ley. Por ello, este Árbitro de Emergencia no considera que corresponda la aplicación del control difuso sobre la modificación del artículo 8° del Decreto No 1071 efectuada por medio del Decreto de Urgencia N° 020-2020.

104. Por ello, en atención a la modificación normativa anteriormente citada, corresponde a esta Árbitro de Emergencia disponer que se constituya Carta Fianza por el 10% del monto del Contrato dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada con esta Decisión Cautelar.

---

[7] Fundamento Jurídico 26 de la Sentencia recaída en el Expediente No 00142-2011-PA/TC-Sociedad Minera de Responsabilidad Ltda. Maria Julia,. S emitida el día 21 de setiembre de 2011.

105. Asimismo, se precisa que la Carta Fianza deberá contar con las siguientes características:

a) Ser solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la Municipalidad Distrital de San Salvador de Quije.

b) La Carta Fianza deberá contener el siguiente texto: "La presente carta fianza garantiza los daños y perjuicios ocasionados a la Municipalidad Distrital de San Salvador de Quije como consecuencia de la ejecución de la medida cautelar en el **Expediente N° 08-2023-CEAS-CA-CECARD/AYA**".

c) La Carta Fianza deberá mantenerse vigente hasta el final del proceso arbitral.

106. Finalmente, sobre los requisitos para solicitar la ejecución de la Carta Fianza, la Entidad deberá acreditar ante el Tribunal Arbitral que emita el Laudo sobre las controversias, los daños que hayan sido generados producto de la medida cautelar, para que, en caso exista un resultado desfavorable al Contratista, se ejecute la Carta Fianza por dicho monto.

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, **el Árbitro de Emergencia DECIDE:**

1. **DECLARAR FUNDADA** la solicitud medida cautelar presentada por HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.; en consecuencia se **CONCEDE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR** a favor de HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., hasta que se adopte la decisión definitiva a través del laudo arbitral; y, por tanto, se **ORDENA** A la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE se abstenga de solicitar la ejecución de las siguientes cartas fianzas:

   i) La Carta Fianza E0642-02-2023, emitida por Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantía, por el monto de S/ 531,888.70, como garantía de adelanto de materiales correspondiente a la Adjudicación Simplificada Nº 001-2022-MDSSSQ/CS;

   ii) La Carta Fianza E4471-01-2022, emitida por Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantía, por el monto de S/ 279,972.98, como garantía de fiel cumplimiento del contrato correspondiente a la Adjudicación Simplificada Nº 001-2022-MDSSQ/CS y;

   iii) La Carta Fianza E4477-03-2022, emitida por Secrex Compañía de Seguros de Crédito y Garantía, por el monto de S/ 220,764.25, como

garantía por el adelanto directo correspondiente a la Adjudicación Simplificada Nº 001-2022-MDSSQ/CS.

2. **PONER EN CONOCIMIENTO** la presente Decisión a la empresa **SECREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA**, en el domicilio ubicado en Av. Víctor Andrés Belaúnde Nº 147. Edif. "Real Diez", ofic. 601 del Centro Empresarial Real – San Isidro – Lima.

3. **DISPONER** que HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. presente una carta fianza por el 10% del Monto del Contrato.

4. **OTORGAR** a HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. un plazo de veinte (20) días hábiles para que presente la Carta Fianza dispuesta como contracautela, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la medida cautelar.

Carol Yanely Apaza Moncada
Árbitro de Emergencia